

1526080-87.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais

Magistrado: MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/02/2022

... do art. 273, § 1º-B, I, com o crime de tráfico de drogas, também previsto como um delito contra a saúde pública. A pena do tráfico de drogas vai de 5 a 15 anos de prisão. Além disso, a Lei de drogas prevê uma causa de diminuição de pena de 1/6 a 2/3 para pequenos traficantes (art. 33, § 4º), de modo que a sua pena inicial poderá partir de 1 anos e 8 meses de prisão, com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1526080-87.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526080-87.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SISENANDO JOSE BIRALDI

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Vistos.

SISENANDO JOSÉ BIRALDI foi denunciado e se é processado pela prática dos crimes descritos no artigo 273, § 1º e § 1º-B, inciso I, e art. 297, ambos c/c art. 61, inciso II, "j", e art. 69, caput, todos do Código Penal, porque, (i) no dia 27 de outubro de 2021, durante a vigência do Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020, prorrogada pelo Decreto Estadual nº 65.502/2021 (calamidade pública), por volta das 15h30min, nos estabelecimentos comerciais situados à Rua Senador Feijó, nº 14 e nº 29, 3º andar, Sala 310, Sé, nesta cidade e comarca, tinha em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar a consumo, 30 (trinta) cartelas, com 312 (trezentos e doze) comprimidos ao todo, de "Cytotec", produto este destinado a fim medicinal, sem o registro exigido por parte do órgão de vigilância sanitária competente; (ii) em data incerta, porém anterior ao dia 27 de outubro de 2021, durante a vigência do Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020, prorrogada pelo Decreto Estadual nº 65.502/2021 (calamidade pública), nesta cidade e comarca, falsificou, no todo, documentos públicos, consistentes em 08 (oito) atestados médicos, sendo dois deles do Hospital Regional Sul, com carimbo do médico "Augusto Armando de Lucca Junior", e os outros seis do Santa Casa de

Misericórdia de Santo Amaro, com carimbo da médica "Vanessa Armenio Scontre". Recebida a Denúncia, o acusado foi citado, apresentando Resposta à Acusação, seguindo-se a decisão saneadora.

Em audiência foi colhida a prova oral e interrogado o acionado.

Ponderações finais das partes em debates.

Laudo Pericial das substâncias apreendidas (cartelas contendo 312 comprimidos da substância denominada "Cytotec"), a fls. 210/214.

Laudo Pericial dos 08 (oito) atestados médicos falsos, a fls. 215/221.

É o relato do quanto necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é parcialmente procedente.

A materialidade do crime previsto no art. 273, § 1º e § 1º-B, inciso I, do Código Penal encontra esteio no Boletim de Ocorrência de fls. 02/6, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 11 e Laudo Pericial de fls. 210/214, onde se infere que os materiais apreendidos com o acionado, se tratavam, efetivamente, de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, sujeitos a controle da autoridade de vigilância sanitária competente.

Conforme bem apontou o exame pericial, a substância misoprostol "tem uso aprovado pela ANVISA para indução de aborto, esvaziamento uterino por morte fetal ou indução de trabalho de parto, não sendo permitido para utilizações diversas das mencionadas. O medicamento Cytotec não possui registro na Anvisa. O misoprostol só pode ser adquirido por hospitais cadastrados e credenciados para procedimentos abortivo previstos em lei, e ministrado a partir de medicamento aprovado pela Anvisa;" (destaquei).

A autoria do crime acima, imputado ao acionado ecoa da prova produzida.

Entretanto, quanto à imputação da prática do crime previsto no art. 297, caput, do Código Penal, melhor sorte não assiste à acusação.

Como será detalhadamente exposto, não restou provado ter o réu falsificado os atestados médicos apreendidos, em relação aos quais tinha, quando muito, somente a posse indireta e absolutamente duvidosa, diga-se.

Não bastasse, referidos documentos sequer estavam preenchidos, o que põe em dúvida sua subsunção à figura típica.

Interrogado na fase policial, o acionado silenciou (fls. 15).

Em Juízo, admitiu a posse dos comprimidos. Entretanto, justificou sob o prisma de que se trata de remédio para gastrite, certo que, se alguém quisesse, poderia vender por cerca de cinquenta reais.

Ouvidos em audiência judicial, os policiais civis Emerson Rocha dos Santos e Eduardo Keith Hirose apresentaram declarações absolutamente consonantes, no sentido de que, no dia em questão, em cumprimento a uma Ordem de Serviço recebida, dirigiram-se aos endereços localizados à Av. Senador Feijó, números 14 e 29, Sé, nesta Capital, a fim de apurar denúncias recebidas sobre a comercialização de fármacos e outros produtos irregulares. Inicialmente, compareceram à banca localizada no referido endereço, numeral 14, onde foram recebidos pelo ora acusado, SISENANDO JOSÉ BIRALDI, que se identificou como responsável pelo local a autorizou a revista. Ato contínuo, em revista na mencionada banca, localizaram ocultos atrás de garrafas de vidro, 2 (duas) cartelas contendo a inscrição "Cytotec" e ainda 1 (um) envelope contendo 8 (oito) atestados médicos de instituições públicas de saúde, todos em branco, contendo carimbos de médicos, porém, sem assinatura.

Indagado acerca dos objetos encontrados na banca, SISENANDO negou ser de sua propriedade ou conhecer a origem. Em continuidade às diligências investigativas, indagado, SISENANDO confirmou que no outro endereço localizado na mesma avenida, mas no nº 29, havia uma espécie de depósito de sua responsabilidade, entregando as chaves do local, para onde rumou o policial Eduardo, que se fez acompanhar do zelador/porteiro, havendo suspeita de tratar-se do local de estocagem dos remédios vendidos irregularmente. Confirmado que as chaves fornecidas pelo acionado abriram a sala, o policial Emerson foi convocado ao local para lá comparecer, acompanhado de SISENANDO, sede em que, numa revista minuciosa no local, localizaram em uma estante e ocultas no forro de gesso, diversas outras cartelas, semelhantes às encontradas na banca, contendo a inscrição "Cytotec", sendo que, no total, foram

apreendidas cerca de 30 (trinta) cartelas, contendo 312 (trezentos e doze) comprimidos de "Cytotec". Indagado no local dos fatos acerca de todos os objetos localizados, o indiciado se manteve silente, deixando de apontar a origem dos produtos e atestados ou exibir documentação que autorizasse sua posse, motivo pelo qual foi conduzido à presença da autoridade policial.

Consolida a prova, os relatos da testemunha de Defesa Israel, que confirma estar sob responsabilidade do acionado a escritório localizado no numeral 29 da via, sede em que houve a incursão policial.

Neste quadro, dúvida não me paira de que o acionado, nas circunstâncias narradas na Denúncia, tinha em depósito para a venda, ou de qualquer forma, distribuir ou entregar a consumo, produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, contendo a substância misoprostol, sujeita a controle da autoridade de vigilância sanitária competente, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme anteriormente exposto, reitero que, segundo o exame pericial, a substância misoprostol "tem uso aprovado pela ANVISA para indução de aborto, esvaziamento uterino por morte fetal ou indução de trabalho de parto, não sendo permitido para utilizações diversas das mencionadas. O medicamento Cytotec não possui registro na Anvisa. O misoprostol só pode ser adquirido por hospitais cadastrados e credenciados para procedimentos abortivo previstos em lei, e ministrado a partir de medicamento aprovado pela Anvisa;" (destaquei).

Desta forma, é certo que todas as cartelas de Cytotec localizadas sob responsabilidade do acionado não poderiam ser por ele comercializadas, mantidas em depósito ou distribuídas sem a autorização do órgão regulamentar, mormente em razão de seu potencial abortivo, pelo qual é notoriamente conhecido e procurado.

Assentada a materialidade delitiva, tenho para mim que a autoria restou igualmente comprovada.

Consigno que nada há nos autos a indicar que os policiais, por motivo egoístico ou leviano, tivessem urdido macabra trama, como única pretensão na vida acusar a acionada, sabendo se tratar de pessoa inocente.

No caso em espécie, nenhuma razão séria foi levantada para que se colocasse em dúvida a idoneidade das testemunhas policiais ou gerassem suspeita de especial motivo para prejudicar a acusada.

Com efeito, foi o réu surpreendido em flagrante delito, mantendo em depósito inúmeras cartelas de Cytotec, medicamento abortivo, à base de misoprostol, esta última que se trata de substância controlada, relacionada na lista C1 da Portaria 344/98 da ANVISA, fato este absolutamente incriminador e para o qual o réu não conseguiu fornecer qualquer explicação minimamente convincente pela qual se pudesse afastar sua responsabilidade pelo crime a ele imputado.

De tal forma, da prova se extrai que efetivamente o acusado praticou a conduta descrita na Denúncia.

A destinação mercantil dos produtos também é evidente e decorre, inclusive, do contexto em que localizados os medicamentos irregulares, vale dizer, escondidos na banca e no depósito onde o réu realiza diversas transações comerciais lícitas, tudo levando a crer que SISENANDO efetivamente se utilizava de seu estabelecimento para, também, praticar a atividade criminosa em comento, de forma oculta e sem despertar suspeitas.

Assim, quanto à imputação da prática do crime previsto no art. 273, § 1º e § 1º-B, inciso I, do Código Penal as provas confirmaram os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

Já no que concerne à acusação da prática do crime previsto no art. 297, caput, do Código Penal, ou seja, do crime de falsificação de documento público, respeitados entendimentos divergentes, considero que a absolvição é medida que se impõe.

Com efeito, narraram os policiais que, em revista à banca do acusado, foram encontrados oito atestados médicos em branco, porém, contendo carimbos de médicos diversos.

Conforme se verifica nas fotografias de fls. 52/55, tais documentos estavam, de fato, com seus campos para preenchimento absolutamente em branco, possuindo, apenas, o carimbo de algum médico - mesma constatação colocada no Laudo Pericial de

fls. 215/221.

Observo que o tipo penal em tese violado descreve a conduta de quem falsifica, no todo ou em parte, documento público, ou altera documento público verdadeiro. Ora, no caso dos autos, foram apreendidas cópias de atestados médicos sem qualquer preenchimento ou assinatura, ou seja, se havia a intenção de alguém de cometer o crime em apreço, tal não chegou a ser colocada em prática, na medida em que atestados em branco evidentemente não podem ser considerados “falsos”, eis que ausente materialidade delitiva.

No ponto, necessária fazer a distinção entre o falso material – crime pelo qual está o réu sendo acusado – e o falso ideológico, ou seja, quanto ao conteúdo daquilo que consta documentado.

Quanto a este último, não podem os documentos em questão se referir, na medida em que, conforme acima colocado, não há conteúdo algum nos atestados, o que esvazia qualquer possibilidade de se ver caracterizado o delito previsto no art. 299 do Código Penal.

E, quanto ao primeiro, que é verdadeiramente o objeto da acusação, o Laudo pericial de fls. 215/221, que somente poderia se manifestar acerca do suporte material – pois que, friso, conteúdo inexistente – foi inconclusivo, afirmando a nobre expert que “Deixa a signatária de se manifestar a respeito da autenticidade ou falsidade dos suportes de atestados médicos, descritos no capítulo Peça(s) de Exame, tendo em vista que documentos desta natureza não possuem elementos de segurança em sua confecção.”.

Neste cenário, não havendo prova de que os documentos seriam falsificados, ou seja, de que não seriam suportes reais para atestados médicos utilizados pelos referidos nosocômios, poder-se-ia eventual falsificação ou alteração de documento verdadeiro incidir sobre escritos colocados nos documentos, inclusive relacionados às assinaturas dos médicos cujo carimbo se encontra gravado nos atestados.

Entretanto, como não há qualquer preenchimento, não há como se concluir tenha havido algum tipo de falsificação ou alteração em tais documentos.

E não só!

Ainda que se pudesse afirmar que os atestados apreendidos são falsos, não há prova segura capaz de acarretar a conclusão de que foi o réu o autor do crime, ou seja de que o acionado realizou o núcleo do tipo ou concorreu de alguma forma para a sua realização, na medida em que o só fato de terem sido encontrados em sua posse não serve para lastrear tal entendimento.

Diante de tal quadro, entendo tímida e precária a prova acusatória, de todo rasa, resumida a mera suspeita, esta que não convence meu íntimo, e, verdadeiramente, me atormenta a convicção, sendo de rigor o pronunciamento do non liquet.

Em situação parelha: É certo que há suspeitas sobre a autoria, mas não um conjunto probatório firme e coeso. Ora, sem que haja uma prova concreta e indubitável, não há sustentação para a condenação. O Direito Penal não opera com meras conjecturas, suposições ou ilações, e se a prova produzida pela acusação não foi suficiente para confirmar a acusação descrita na denúncia, a absolvição do réu é medida que se impõe, em atenção ao princípio do in dubio pro reo. Não é caso de absolvê-lo por “estar provado que não concorreu para a infração penal” (art. 386, IV, do CPP) como pretende a defesa, porque, como já dito, há um elemento nos autos que o aponta como autor. O mais adequado, portanto, é o acolhimento do pedido subsidiário, ou seja, a absolvição por “não existir prova suficiente para a condenação” (art. 386, VII, do CPP). Heleno Cláudio Fragoso (Jurisprudência Criminal, Editora Forense, 4ª edição, página 506), observava: “Não é possível fundamentar sentença condenatória que não conduza à certeza. Esse é um dos princípios basilares do processo penal em todos os países democráticos. A condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno da existência de certa realidade”. Acerca dessa matéria: “O Direito Penal não opera com conjecturas. Sem a certeza total da autoria e da culpabilidade não pode o juiz criminal proferir condenação” (Apelação 170.407, TACRIM-SP). “Aplicação do princípio in dubio pro reo. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para a condenação criminal exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, 'a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica

e exata como a matemática'. Deram parcial provimento unânime" (RJTJESGS 177/136) (Apelação nº 0016929-51.2012.8.26.0564, j. em 24 de agosto de 2015, rel. Desembargador Diniz Fernando).

Portanto, havendo prova precária que corrompa o espírito do julgador, a solução absolutória se mostra como medida de rigor.

Confira-se: Por suas gravíssimas consequências, decreto condenatório não deve ser expedido, exceto se comprovadas, sem falta, a materialidade e a autoria do crime e a culpabilidade do agente. Vêm aqui de molde, pois, estas palavras do eminente Magistrado Hoepfner Dutra: "Na Justiça penal, tudo deve ser certo e preciso como uma equação algébrica. Os elementos probatórios de uma acusação penal devem ser espontâneos, lógicos, consistentes, precisos, harmônicos e, sobretudo, concordantes, para que apresentem em si uma inteireza real a sobrelevar a evidência da verdade. Forçá-los com artifícios é mostrar o intuito de criar uma situação moral grave que, afinal, compromete o resultado da investigação e os objetivos da própria Justiça. Assim sendo, desde que para chegar a uma conclusão a dúvida assalte a consciência de quem julga, o valor de certas provas enfraquece e, por consequência, deve ser preferida a improcedência de uma acusação a um injusto pronunciamento condenatório" (TacrimsP; Ap. n- 18.186 - São Paulo; j . 30.10.59; v.u.). O princípio geral de que toda a decisão condenatória deve assentar em prova plena e cabal (não só da materialidade do fato criminoso senão também da autoria e culpabilidade do agente) manda afastar da cabeça do réu o gládio da Justiça, nos casos de dúvida invencível. Isto mesmo proclamam nossos Tribunais: "Não basta para a concretização de uma sentença condenatória a simples soma de indícios, por mais veementes que sejam em desfavor do acusado. Ainda mais quando tais indícios foram devidamente contrariados por ampla prova em sentido contrário, restando sérias dúvidas que, em matéria penal, equívalem à ausência de provas (Rev. Tribs., vol. 436, p. 346). Mais que meras conjecturas acerca da culpabilidade do acusado, são necessárias, para sua condenação, provas tão claras como a luz meridiana: "probationes luce meridiana clariores " (çf. Giovanni Brichetti, L 'Evidenza nel Diritto Processuale Penale, 1950, p. 111). Assim, para que o réu não fosse condenado por crime sem prova cabal de autoria e, pois, de culpa, não havia senão pronunciar o "non liquet" e mandá-lo em paz. (Apelação nº 993.03.048470-4, rel. Desembargador Carlos Biasotti).

Bem firmada a responsabilidade do acionado pela prática, unicamente, do crime previsto no art. 273, § 1º e § 1º-B, inciso I, do Código Penal, passo a mensurar as reprimendas adequadas.

Antes, todavia, imperioso observar que o E. Supremo Tribunal Federal, no RE nº 979.962/RS, de relatoria do eminente Min. Roberto Barroso, julgado em 24/3/2021, com repercussão geral reconhecida, declarou inconstitucional, por violação aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena, a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1ºB, I, que versa sobre a importação, venda, exposição à venda, depósito, distribuição ou entrega a consumo, de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Com efeito, na oportunidade, foram retomadas as penas originais do preceito incriminador em questão, em virtude do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade.

Na oportunidade, asseverou o nobre Ministro Relator, Dr. Luís Roberto Barroso, em seu voto (destaques por este magistrado):

44. O crime do art. 273, § 1º-B, I, no entanto, pune com a mesma pena de dez a quinze anos aquele que simplesmente negocia medicamento sem o registro no órgão de vigilância sanitária competente. O tipo penal não exige sequer que o medicamento tenha potencial de lesionar a saúde ou a vida de alguém, nem que o agente o adultere ou falsifique; basta a ausência do registro obrigatório para a caracterização do delito. 45. A desproporcionalidade salta aos olhos. Nos outros delitos assemelhados mencionados, o legislador, de modo razoável, previu penas menores para condutas relacionadas claramente menos lesivas ao bem jurídico. Assim, diferentemente da conduta de envenenar água potável (punida com prisão de 10 a 15 anos), a ação de "corromper ou poluir água potável, de uso comum ou particular,

tornando-a imprópria para consumo ou nociva à saúde" é sancionada com prisão de dois a cinco anos (CP, art. 271); diversamente da conduta de causar epidemia (também punida com prisão de 10 a 15 anos), a pena do médico que deixa de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória vai de 6 meses a 2 anos de prisão (CP, art. 269). 46. No caso sob exame, porém, o legislador não fez a distinção necessária de acordo com a gravidade das condutas, tratando de modo igual situações diametralmente diferentes. Previu a mesma pena para quem falsifica ou adultera medicamentos – condutas que geram efeitos gravíssimos, pois é de se esperar que o medicamento se torne inócuo (nocividade negativa) ou mesmo produza efeitos colaterais graves (nocividade positiva) – e para quem simplesmente negocia medicamentos sem registro. 47. Compare-se o delito do art. 273, § 1º-B, I, com o crime de tráfico de drogas, também previsto como um delito contra a saúde pública. A pena do tráfico de drogas vai de 5 a 15 anos de prisão. Além disso, a Lei de drogas prevê uma causa de diminuição de pena de 1/6 a 2/3 para pequenos traficantes (art. 33, § 4º), de modo que a sua pena inicial poderá partir de 1 ano e 8 meses de prisão, com possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade. (...) 50. Na comparação com tipos penais protetores de outros bens jurídicos, a desproporcionalidade torna-se ainda mais evidente. A pena mínima da comercialização de medicamentos sem registro é maior do que a prevista para o estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), para a extorsão mediante sequestro (CP, art. 159) e para a tortura seguida de morte (Lei nº 9.455/1997, art. 1º, § 3º). 51. Finalmente, vale mencionar que: a) a doutrina tem sustentado há muito tempo – e, até onde pude constatar, de forma unânime – a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1º-B, I31; e b) o STJ, em julgado de 2015, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do dispositivo do art. 273, § 1º-B, V, do CP, que prevê a mesma conduta aqui examinada, mas relacionada a produtos "de procedência ignorada" (AI no HC 239.363/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, j. 26.02.2015).

Finalmente, como solução para o reestabelecimento da proporcionalidade em relação ao crime e sua respectiva pena, decidiu-se, conforme colocado na parte final do voto do eminente relator:

"66. A maioria dos Ministros desta Corte, porém, entendeu que, como decorrência automática da declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1º-B, I, incidiria o efeito repristinatório sobre o preceito secundário do art. 273, caput, na redação original do Código Penal, que previa pena de 1 a 3 anos de reclusão. 67. Diante disso, reajusto meu voto no sentido acolhido pelo Plenário, determinando a devolução dos autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para aplicação da pena prevista para o art. 273, caput, na redação original do Código Penal."

Por derradeiro, no julgamento cujo excerto colacionei acima, restou fixada a seguinte, sob repercussão geral, friso:

"É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)".

Assim, frente às novas balizas colocadas pela Suprema Corte, passo a dosar a pena do acionado.

Em primeira fase, as circunstâncias judiciais se mostram de todo desfavoráveis.

A uma, por conta do volume do material proibido, mais de trezentas doses.

A duas, pela qualidade do material, produto abortivo.

A três, verifico que o réu ostenta maus antecedentes, decorrente de condenação transitada em julgado, cuja punibilidade foi declarada extinta há mais de cinco anos (art. 64, inciso I, do CP), referente ao processo nº 011356-51.2014, que tramitou na 21ª Vara Criminal Central (fls. 161/162), por situação parelha.

Importante destacar que o Pretório Excelso no julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.818, com repercussão geral reconhecida, fixou, por maioria de votos, a tese de que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo

quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal". Por tal motivo, fixo a pena base em patamar superior ao mínimo, culminando no cumprimento de pena privativa de liberdade de dois anos de reclusão e pagamento de vinte dias multa.

Em segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes, visto que o acionado, verdadeiramente, não confessou a prática, apresentando evasivas, doutro lado é de rigor o reconhecimento da agravante genérica descrita no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, tendo em conta a data dos fatos (27.10.2021), e a edição do Decreto nº 64.879, de 20.03.2020, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, esta que, necessário consignar é de natureza objetiva, consoante leciona a doutrina: As circunstâncias agravantes genéricas são de caráter pessoal ou subjetivas, quanto: a) ao móbil do injusto ou à finalidade de agir (v.g.: motivo fútil ou torpe para facilitar ou assegurar a execução ou ocultação ou impunidade ou vantagem de outro injusto, ou por motivo de lucro); b) a qualidade ou condição pessoal do agente (embriaguez preordenada, com abuso do poder ou abuso de autoridade); c) quanto às relações do autor do ato com o sujeito passivo ou com os outros partícipes (parentesco, relações domésticas, de coabitação, ou hospitalidade; promovendo, organizando a cooperação ou dirigindo a atividade criminosa; instigando, coagindo a execução delitiva). Já as circunstâncias agravantes genéricas são de caráter objetivo, quanto: a) aos meios e modos de execução (traição, emboscada, dissimulação, emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura); ao tempo e lugar (por ocasião de incêndio, naufrágio, calamidade pública); c) à pessoa ou à condição da vítima (criança, velho, enfermo, pessoa sob estado de desgraça particular, ou pessoa sob imediata proteção da autoridade. (página 405, Direito Penal, Parte Geral, volume 3, 7ª edição, Álvaro Mayrink da Costa); O agente não cria, como na letra d, mas aproveita os efeitos da calamidade pública (além dos exemplos legais: seca, epidemia, guerra, extrema e geral carestia da vida, invasão armada, insurreição, certas greves, etc.) que, por natureza, atinge a coletividade, ou de calamidade particular (acidente, falência, infortúnios domésticos e pessoais em geral, etc.). Em todos os casos, a maior periculosidade define-se pela falta dos requisitos primários da solidariedade humana, pela completa ausência de senso moral. O agente não só desatende a imperativos éticos rudimentares, como não se detém diante dos supremos espetáculos da dor e do perigo, e ainda encontra neles sugestões e estímulos para aumentar a aflição dos aflitos. (página 299, Comentários ao Código Penal, volume 2, 2ª edição, Roberto Lyra); Situações de calamidade pública, como incêndios, inundações, ou mesmo naufrágios, ou de desgraça particular, como acidentes de trânsito, representam condições concretas adversas que reduzem ou excluem a capacidade de proteção pessoal ou patrimonial das vítimas, aumentando a reprovabilidade das ações lesivas de bem jurídicos penalmente protegidos. (página 578, Direito Penal, Parte Geral, 2ª edição, Juarez Cirino dos Santos)

Bem por isso, então, respeitado sempre o entendimento da Defesa, não reclama qualquer nexó entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e o crime cometido, máxime porque acerca da edição da norma que decretou o estado de calamidade pública, advinda da autoridade competente a nível Federal e Estadual, não pode o acionado alegar inciência, pena de fazer letra morta do disposto no art. 3º, da LINDB (Decreto-Lei 4.657/42), in verbis: Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.

Deste modo, exaspero as reprimendas anteriormente aplicadas em 1/6, culminando no cumprimento de pena privativa de liberdade de dois anos e quatro meses de reclusão, além do pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a vinte e quatro dias multa, fixados estes em seu valor unitário mínimo legal, reprimendas estas que torno definitivas, na medida em que ausentes causas de aumento ou diminuição de penas.

Em razão do quantum da pena corporal ao final aplicada, bem como considerando que o réu se trata de pessoa tecnicamente primária, que cometeu crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, entendo suficiente e adequada a fixação do regime aberto como inicial para desconto da reprimenda corporal, nada reclamando maior rigor. Outrossim, considerando, presentes os requisitos e fundamentos legais, substituo a

pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, bem como por uma pena de multa, fixada esta em valor equivalente a dez dias multa, no mínimo legal, tudo nos termos do art. 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal.

Acredito que mais, seja desnecessário aduzir, posto que nada mais pertine à análise, como forma de dirimir a controvérsia instalada.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e assim o faço para ABSOLVER o acusado SISENANDO JOSÉ BIRALDI da prática do crime previsto no art. 297, caput, do Código Penal, o que faço nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como para, doutro lado, CONDENÁ-LO ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial aberto, além do pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a 24 (vinte e quatro) dias multa, fixados estes em seu valor unitário mínimo legal, por infringência ao disposto no artigo 273, § 1º e § 1º-B, inciso I, do Código Penal. Presentes os requisitos legais, SUBSTITUO a pena corporal aplicada por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, bem como por uma pena de multa, fixada esta em valor equivalente a dez dias multa, no mínimo legal, tudo nos termos do art. 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal.

Tendo respondido ao processo em liberdade, em caso de recurso, concedo ao réu o direito de apelar nesta mesma condição, mormente em se considerando as penas ao final impostas.

Transitada esta em julgado, que seja o nome do sentenciado lançado no rol dos culpados.

Arcará o condenado com o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03.

Sentença dada e publicada em audiência, saindo os presentes cientes e intimados.

P.R.I.C.

São Paulo, 09 de fevereiro de 2022.

Marcio Lucio Falavigna Sauandag
Juiz de Direito Titular I da 22ª Vara Criminal Central

Assinatura digital, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea "a", da Lei Federal nº 11.419/06